

1501816-91.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... reais) em notas trocadas, fruto do tráfico e 01 motocicleta Honda CG 160 Start, cor preta e placa EMS7H29, utilizada na prática do tráfico de drogas.

Recebida a denúncia em 22/08/2022 (fls. 81), foi o réu citado (fls. 153) e, por meio do seu defensor, apresentou defesa prévia (fls. 111/113).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501816-91.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501816-91.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194455/2022 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 26201236 -

DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2194455 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

PAULO SÉRGIO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, consoante documento inicial acusatório, por volta das 16h50min do dia 18 de julho de 2022, na Rua Regente, nº 20, Jardim Cruzeiro, em de Franco da Rocha/SP, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, as seguintes drogas: a) 64 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 141,53g de massa bruta e b) 103 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 111,14g de massa bruta; substâncias proscritas

conforme portaria SVS/MS 344/1998, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 18/20 e laudo toxicológico a ser juntado, além da quantia de R\$6,00 (seis reais) em notas trocadas, fruto do tráfico e 01 motocicleta Honda CG 160 Start, cor preta e placa EMS7H29, utilizada na prática do tráfico de drogas.

Recebida a denúncia em 22/08/2022 (fls. 81), foi o réu citado (fls. 153) e, por meio do seu defensor, apresentou defesa prévia (fls. 111/113).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas e o réu foi interrogado ao final da instrução.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima.

É o relatório.

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição de apreensão (fls. 10/11), pelo laudo de constatação (fls. 18/20) e laudo pericial definitivo (fls. 93/95), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Em juízo disse que os fatos são falsos. Disse que pegou a moto de seu cunhado emprestada para buscar sua esposa, tendo deixado ela em casa. Quando estava passando ao lado da viatura, os guardas abriram a porta, razão pela qual o depoente parou. O guarda rasgou sua camisa e o ameaçou. Disse que não tinha habilitação e não estava com nada ilícito. O depoente disse que tinha passagem por tráfico e os policiais passaram a conversar em separado. Sua irmã chegou ao local. Cerca de dez minutos depois os policiais retornaram e disseram que estava preso. Ficou na delegacia esperando no estacionamento até ser preso. Negou-se a assinar qualquer documento. Já viu os guardas de passagem na rua. Não sabe o motivo que eles teriam para lhe imputar fatos criminosos. Trabalhava em um salão de cabeleireiro. O local tem residência e tem um bar nas proximidades. Pegou essa motocicleta emprestada por cerca de três vezes com seu cunhado, que trabalhava como motoboy.

A versão do acusado não guarda amparo na prova dos autos.

A testemunha Wagner Aparecido de Santana Leite, na Delegacia de Polícia, afirmou que a equipe estava em patrulhamento pelo local dos fatos que já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes quando, ao realizar uma curva, veio de frente com a viatura uma moto preta CG 160 Start placa EMA7H29, onde o condutor esboçou certo nervosismo e tentou se evadir onde se desequilibrou ao subir na calçada e veio ao solo. O condutor se levantou e arremessou uma sacola na mata. Ato contínuo, o condutor foi abordado e qualificado como Paulo Sérgio Santos Da Silva e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ao localizarmos a sacola por ele arremessada, foram localizados os entorpecentes e dinheiro apreendidos sendo, 103 porções de pó branco aparentando ser cocaína, 64 porções de substância esverdeada

aparentado ser maconha e R\$ 6,00 reais em dinheiro. indagado o mesmo informou ter pego a moto emprestada para realizar o transporte dos entorpecentes que estavam na sacola por ele arremessada. Diante dos fatos e da materialidade delitiva o mesmo foi conduzido junto aos entorpecentes e a motocicleta para a delegacia de polícia civil de Franco Da Rocha .

No seu depoimento em juízo, a testemunha afirmou que é guarda municipal em patrulhamento por local conhecido pela venda de drogas. No local, viram o réu que veio a cair de uma motocicleta em uma conversão, razão pela qual pararam para auxiliar. Nesse momento, o réu arremessou uma sacola, com a aproximação dos guardas. Em poder do réu não encontraram nada de ilícito. Recuperada a sacola, em seu interior encontraram os entorpecentes. O réu disse que estava em transporte dessa droga para o local de venda. Não conhecia o réu antes desses fatos. No momento em que passaram não havia outras pessoas no local. O ponto de venda é na mesma via em que o réu foi abordado, há cerca de 30 metros do local. Apareceram pessoas dizendo que sabiam quem era o dono da moto, dizendo que a moto seria apresentada na delegacia. A abordagem se deu pelo nervosismo do réu com a presença da viatura, o que inclusive ocasionou sua queda.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Anderson Ferreira de Oliveira, na ocasião do flagrante, o qual disse que é Guarda Municipal em Franco da Rocha, mantendo o mesmo relato do seu colega de profissão.

No seu depoimento em juízo, disse que encontrou o entorpecente no barranco nas proximidades de onde o réu arremessou. A abordagem, na verdade, foi motivada para auxiliar o réu devido à queda, não tendo ideia de que estaria ocorrendo algo de ilícito, até que o réu arremessou a sacola. Não havia denúncias prévias envolvendo o réu e nem a moto. Não se recorda se familiares do réu ou o proprietário da moto chegaram ao local.

Maria Julia Santos da Silva, irmã do acusado, ouvida como informante, disse que foi para a casa de sua mãe e seu irmão pediu a moto emprestada para buscar sua esposa. Depois de cerca de 30 minutos ouviu uma bagunça na rua dizendo que seu irmão estava sendo preso. Encontrou seu irmão sentado algemado e o guarda municipal impediu que a depoente se aproximasse dele. Uma outra viatura chegou ao local e foi informado que ele estava sendo preso por tráfico de drogas. Na delegacia viu uma malinha de entorpecentes. Os guardas não explicaram como se deu a prisão. Seu irmão não pegava a moto com frequência emprestada, sendo esta de propriedade de seu esposo. A casa de sua mãe é perto do local onde seu irmão foi preso e não sabe onde tem ponto de venda de entorpecentes nas proximidades.

Igor Pereira dos Santos, cunhado do réu, ouvido como informante, disse que não acompanhou a prisão do réu. Está com essa motocicleta há seis meses, mas o réu não tinha costume de pegar essa moto emprestada, o que aconteceu poucas vezes. Essa motocicleta é financiada e o depoente utilizava para trabalho. Sabia que o réu tinha uma passagem anterior por tráfico de drogas.

Quanto aos agentes de segurança ouvidos, não há indícios de que tinham motivos para acusar o réu de forma leviana e gratuitamente, até porque sequer o conheciam.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido."(JTJ 208/273).""Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas

testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo." (TACrim,12ªCâmara , rel. Desembargador João Morenghi, Apelação1473255/5).

Não é crível que os guardas municipais pudessem ter em seu poder tamanha quantidade e diversidade de drogas somente para imputar responsabilidade ao recorrente, destacando que a defesa não apontou qualquer animosidade entre o réu e os policiais, de maneira que não há nada que mitigue a validade de seus depoimentos, resultando a autoria do réu incontroversa.

Nem se fale que a prova é problemática seja pela ausência de outros depoimentos estranhos aos órgãos policiais ou ainda pela falta de imparcialidade do testemunho dos guardas. Atualmente é notório que, nos crimes de tráfico, os testemunhos de civis, alheios aos quadros policiais, são cada vez mais raros, ante o medo que norteia a população no tocante ao citado delito, sentimento compreensível pela estruturação advinda dele, fomentada pelo grande lucro envolvido e pelo conhecido Código de Ética, principalmente nos locais mais humildes, o que culmina, conseqüentemente, com a perda da própria vida dos colaboradores.

Dessa forma, deve o depoimento dos guardas municipais ser tido como outro qualquer, ou seja, para desacreditá-lo, é necessário demonstrar a invalidade concreta e não apenas suposta. E a própria versão apresentada pelo réu- negativa de autoria - é inaceitável e ficou divorciada do conjunto probatório.

Portanto, o testemunho dos guardas municipais merece fé até prova em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em falsamente incriminar o réu, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra qualquer possibilidade de que os policiais mentiram ou inventaram a diligência para prejudicar de forma injusta o acusado, como também não vislumbro contradições na versão por eles apresentada na fase policial e na instrução judicial.

Também não há que se falar em irregularidade da atuação dos guardas municipais. Como sabido, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Nesta categoria de infrações, o sujeito pratica uma violação da norma penal que se prolonga no tempo. Estará, portanto, em constante estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminoso (art. 303 do CPP).O Código de Processo Penal, em seu art. 301, permite que qualquer pessoa do povo efetue prisão de quem se acha em flagrância delitiva.

É cediço que o art. 144, §8º, da Constituição Federal determina que a Guarda Municipal será destinada à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo, portanto, como principal função a de assegurar a segurança pública, tampouco investigar a prática de crimes. Nada obstante, a referida disposição não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante aquele que estiver cometendo um delito. Tal entendimento não discrepa da aposição consolidada pelos Tribunais Superiores:

Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato da prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda Municipal não revela ilegalidade" (STJ, HC nº 394.112/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03/08/2017)

No mais, merece destaque que, pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, que disciplina o referido art. 144, § 8º, da Constituição, é competência específica das guardas municipais colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social (art. 5º, IV), bem como encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração penal (art. 5º, XIV).

Neste caso, os guardas, em verdade, atuaram no sentido de tentar prestar socorro ao réu, que caíra da motocicleta ao tentar ultrapassar a viatura. Quando deles se aproximaram, viram-no arremessando a sacola, o que despertou fundadas suspeitas de que estaria participando do crime em questão. Pelo narrado, era presumível que ele pudesse estar cometendo um delito, não tendo sido a ação dos guardas decorrente de qualquer investigação prévia, sendo que sequer foram motivados a atuar por fins de abordagem, mas altruísticos.

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana. A quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelos guardas municipais ouvidos, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se pois a sua condenação.

Ainda, há de se mencionar que o fato de ser ou não usuário de entorpecentes, não afasta a situação de traficância e portanto, não há que se falar em desclassificação do delito. Tem-se que a quantidade de entorpecentes encontrada na mochila, a variedade e a forma de acondicionamento (pequenas porções prontas para distribuição) e a ausência de comprovação da origem do dinheiro encontrado demonstram que as substâncias encontradas não se destinavam ao consumo do réu, mas sim a venda.

Desnecessários, ainda, a prática de atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos.

No mesmo sentido:

“Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito” (RJTJSP - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan - Data do julgamento: 06/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a quantidade de drogas apreendida e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como traficante, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500768-62.2021.8.26.0567; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2022)

Por outro lado, não há que se falar que a única prova existente nos autos contra o réu é a palavra dos policiais, pois ainda há, em desfavor dele, a apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas e dinheiro.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, verifico que o réu é primário e possui bons antecedentes. A quantidade de cocaína maconha apreendida não foi expressiva, não havendo razão para exasperar a pena por este motivo. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes a incidirem.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

É de se esclarecer que não é mais possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido foi fixada a tese no julgamento do repetitivo quanto ao REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180 junto ao STJ: " É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006".

Pessoalmente, este juízo discorda da tese jurisprudencial fixada, eis que o fato do acusado possuir inquéritos com datas próximas relativos à apuração de crimes da mesma natureza, como nos autos, é evidência de que este se dedica ao tráfico como meio de vida.

Os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da causa de diminuição de pena.

No caso em curso, o réu responde a outro feito por tráfico de drogas que teria ocorrido em intervalo inferior a um ano antes dos fatos descritos na denúncia (conforme fl. 158 - autos nº 1521720-12.2021.8.26.0228). Não entendo que seja possível ao juízo ignorar tais evidências de comportamento endêmico criminoso, privilegiando o réu nos mesmos moldes daqueles que não ostentam qualquer outro registro criminal anterior.

Ainda, é de se pontuar que, em casos como este em curso, ainda que o acusado venha a ser condenado futuramente por crime de tráfico nos autos relativos a fatos anteriores a este, sequer seria possível o afastamento da causa de diminuição de pena nesta ocasião, eis que não será possível a valoração de fatos posteriores para esse fim. Tal fato, portanto, implicaria em dupla redução de pena a pessoa que foi presa supostamente pelo mesmo crime em intervalo curto de tempo.

No entanto, tendo sido a tese fixada em sede de recurso repetitivo, não resta alternativa que não a sua aplicação por esta magistrada, em respeito ao sistema de vinculação de precedentes

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), observando (na fixação do quantum dessa redução) o que prescreve o art. 42 da mesma lei, tornando definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Nos termos dos artigos 49, § 1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do art, 33. §2º, a do Código Penal, fixo o regime aberto como o inicial ao cumprimento da pena ora aplicada, uma vez que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo.

Neste sentido a jurisprudência:

"O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de 'habeas corpus' para afastar a natureza hedionda de tal delito." (HC 118533, Relatora Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 23.6.2016, DJE de 19.9.2016) "HABEAS CORPOS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA FIXADA EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO". INCONSTITUCIONALIDADE DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO (STF, HC 111.840). POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO."

De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas penas restritivas de direito, consistentes em: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 02 (dois) salários mínimos a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o Réu PAULO SÉRGIO SANTOS DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 02 (dois) salários mínimos a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código.

Defiro ao réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça. Expeça-se guia à VEC.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos para o SENAD. Providencie o necessário.

Quanto à motocicleta apreendida, defiro sua liberação ao proprietário, sem o pagamento de custas, uma vez que não restou provada sua utilização para a traficância, bem como o envolvimento do seu proprietário com a conduta do réu. Comunique-se à delegacia, servindo esta sentença de ofício.

Defiro a gratuidade da justiça, isentando-o do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Franco da Rocha, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA